

1501319-52.2019.8.26.0457
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Valéria Pinheiro Vieira
Comarca: Pirassununga
Foro: Foro de Pirassununga
Vara: 2ª Vara
Data de Disponibilização: 07/02/2022
... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Averiguado:
ANTONIO CARLOS RODRIGUES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Valéria Pinheiro Vieira

Vistos.

Antônio Carlos Rodrigues está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, pois, nos termos da denúncia, no dia 26 de agosto de 2019, por volta ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Pirassununga
Foro de Pirassununga
2ª Vara
Rua José Bonifácio, 70, Pirassununga - SP - cep 13631-062
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1501319-52.2019.8.26.0457 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1501319-52.2019.8.26.0457
Classe - Assunto
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Averiguado:
ANTONIO CARLOS RODRIGUES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Valéria Pinheiro Vieira

Vistos.

Antônio Carlos Rodrigues está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, pois, nos termos da denúncia, no dia 26 de agosto de 2019, por volta das 16h20min, na Rua Santa Rosa, defronte ao nº 308, no bairro, nesta cidade e comarca de Praia Grande, guardava e trazia consigo, para o fornecimento a terceiros, três porções contendo 2,2 gramas de maconha, droga que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinações legais e regulamentares.

Seguido o rito da Lei nº 11.343/06, o réu foi notificado às fls 177 e apresentou defesa prévia às fls. 185/188. A denúncia foi recebida (fls.288/239). Durante a instrução criminal o réu foi interrogado, sendo inquirida duas testemunhas de acusação. Os debates foram convertidos em memoriais. O Ministério Público ofertou seus memoriais às fls. 386/329 e requereu a condenação do réu a desclassificação do crime para porte de drogas para o consumo pessoal. A Defesa pugnou em suas alegações finais acostadas às fls.323/325, pela absolvição ou, subsidiariamente, em caso de condenação, a desclassificação para a infração penal prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

É o relatório.

DECIDO.

O pedido é improcedente.

Interrogado, o acusado asseverou que os policiais encontraram maconha em sua casa, que se destinava ao seu uso, o que foi corroborado pelas testemunhas ouvidas em juízo. Assim, dúvidas não há que a maconha pertença ao réu. Ocorre, contudo, que, ao cabo da instrução processual, a prova se mostrou insuficiente a sustentar a prolação de um édito condenatório para o crime de tráfico de drogas.

Isto porque, o réu falou que as drogas eram para consumo próprio, sendo que é dever da acusação provar a autoria e a materialidade delitiva, ou seja, o ônus da formação de um conjunto probatório coerente, consistente e acima de quaisquer dúvidas, de modo a possibilitar a prolação do édito condenatório é de responsabilidade exclusiva do Ministério Público, sendo certo que, por força do vetusto princípio da presunção de inocência, ao acusado não cabe a prova de sua inocência.

Deste modo, cotejando os elementos de prova produzidos em Juízo, entendo que a condenação do acusado, não possui prova segura apta a tal mister, ante a diminuta quantidade de entorpecentes encontrada em seu poder, sendo que não há qualquer indicativo que estas se destinassem ao comércio ilícito, ao revés, o réu é usuário de drogas, o que foi corroborado pelo laudo toxicológico e pela prova oral coligida aos autos.

Logo, a melhor solução há de ser o reconhecimento do non liquet, pois o processo penal como instrumento público de proteção de liberdades constitucionais individuais, não pode funcionar com meras conjecturas, suposições ou ilações, eis que a autoria e a materialidade devem ficar cabalmente provadas judicialmente, para se justificar um édito condenatório em relação ao crime de tráfico, devendo, pois, ser desclassificada a conduta imputada para aquela inserta no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, considerando a natureza, a quantidade da substância apreendida e a condição pessoal do acusado, nos termos do parágrafo 2º, do referido artigo, como solução benéfica do in dubio pro reo. Conclui-se, destarte, que o arcabouço probatório é seguro e harmônico a demonstrar a prática da infração penal inserta no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, o qual, contudo, o pedido é improcedente.

Fundamento minha decisão afirmando que a 6ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) já retomou o debate para fins de declarar a inconstitucionalidade do artigo 28 da referida Lei, sob o argumento de que 'não há tipificação de conduta hábil a produzir lesão que invada os limites da alteridade, afronta os princípios da igualdade, da inviolabilidade da intimidade e da vida privada e do respeito à diferença, corolário do princípio da dignidade, albergados pela Constituição Federal e por tratados internacionais de Direitos Humanos ratificados pelo Brasil'.

No mesmo sentido, observo a incidência do princípio da insignificância da conduta, apontando que a Primeira Turma do Pretório Excelso, sob a relatoria do Ministro Dias Toffoli, aplicou, de forma pioneira, o princípio da insignificância a caso específico de porte de drogas, esclarecendo que a privação da liberdade e a restrição de direitos do indivíduo somente se justificam quando “estritamente necessários à própria proteção das pessoas”, levando-se em consideração, para tanto, que no caso houve porte de ínfima quantidade de droga (como ocorreu no caso dos autos, em que o réu trazia, para consumo pessoal, tão somente 1,1 gramas de maconha), o que resultou na determinação do trancamento do procedimento penal por ausência de tipicidade material da conduta. Tal posicionamento vem a se consolidar com a proposta da comissão de juristas responsáveis pelo Anteprojeto do Novo Código Penal de descriminalizar o uso de drogas, cabendo ao Poder Executivo regulamentar a quantidade de substância que uma pessoa poderá portar e manter sem que se considere crime.

Veja que a posse de droga para consumo pessoal transformou-se (com a nova lei de drogas) numa infração *sui generis* (art. 28, que não comina pena de prisão). A ela se aplica, isolada ou cumulativamente, uma série de medidas alternativas (advertência, prestação de serviços à comunidade e comparecimento a programa ou curso educativo). Quando, entretanto, se trata de posse ínfima de droga (repito, como ocorreu no caso em questão), o correto não é fazer incidir qualquer uma dessas sanções alternativas, sim, o princípio da insignificância, que é causa de exclusão da tipicidade material do fato. Há duas modalidades de infração bagatelar própria: a primeira reside na insignificância da conduta (desaparece nesse caso o juízo de desaprovação da conduta); a segunda na do resultado (não há que se falar em resultado jurídico desvalioso).

A posse de droga para consumo pessoal configura uma das modalidades do chamado delito de posse, que retrata uma categoria penal muito singular no Direito penal. Mister se faz, para a consumação da infração, constatar a idoneidade ofensiva (periculosidade) do próprio objeto material da conduta. Se a droga concretamente apreendida não reúne capacidade ofensiva nenhuma, em razão da sua quantidade absolutamente ínfima, não há que se falar em infração penal. Não existe, nesse caso, conduta penalmente ou punitivamente relevante, como se deu na hipótese “sub-judice”.

A consequência natural da aplicação do critério da insignificância (como critério de interpretação restritiva dos tipos penais ou mesmo como causa de exclusão da tipicidade material - STF, HC 84.412, rel. Min. Celso de Mello) consiste na exclusão da responsabilidade penal dos fatos ofensivos de pouca importância ou de ínfima lesividade. São fatos materialmente atípicos (afasta-se a tipicidade material, pouco importando se se trata da insignificância da conduta ou do resultado). Se tipicidade penal é tipicidade objetiva ou formal + tipicidade material ou normativa, não há dúvida que, por força do princípio da insignificância, o fato de ínfimo significado é atípico, seja porque não há desaprovação da conduta (conduta insignificante), seja porque não há um resultado jurídico desvalioso (resultado ínfimo).

Sobre a mais adequada consequência dogmática do princípio da insignificância

(exclusão da tipicidade material) paradigmático é o HC 84.412-SP do STF (rel. Min. Celso de Mello). Mais recentemente essa mesma posição foi reafirmada no RHC 88.880, pelo STF (rel. Min. Gilmar Mendes). Depois daquela primeira decisão do STF (de 1988: cf. RTJ 129/187 e ss. - caso de lesão corporal levíssima em razão de acidente de trânsito) cabe assinalar que praticamente toda a jurisprudência brasileira passou a admitir o princípio da insignificância como corretivo da abstração e generalidade do tipo penal. Inclusive em matéria de entorpecentes, apesar das divergências, são numerosas as decisões do Superior Tribunal de Justiça reconhecendo o princípio da insignificância:

"Entorpecente. Quantidade ínfima. Atipicidade. O crime, além da conduta, reclama um resultado no sentido de causar dano ou perigo ao bem jurídico (...); a quantidade ínfima informada na denúncia não projeta o perigo reclamado"1. Sempre "é importante demonstrar-se que a substância tinha a possibilidade para afetar ao bem jurídico tutelado"2. A pena deve ser "necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do delito. Quando a conduta não seja reprovável, sempre e quando a pena não seja necessária, o juiz pode deixar de aplicar dita pena. O Direito penal moderno não é um puro raciocínio de lógica formal. É necessário considerar o sentido humanístico da norma jurídica. Toda lei tem um sentido teleológico. A pena conta com utilidade". "Trancamento de ação penal, crime, porte de entorpecente, maconha, pequena quantidade, inexistência, dano, perigo, saúde pública, aplicação, princípio da insignificância. (voto vencido) (min. Paulo Gallotti) descabimento, trancamento de ação penal, crime, porte de entorpecente, maconha, uso próprio, hipótese, consumo, praça pública, irrelevância, pequena quantidade, caracterização, tipo penal, perigo abstrato, violação, saúde pública." (STJ, HC 21672-RJ, Rel. Min. Fontes de Alencar). "Penal. Entorpecentes. Princípio da insignificância. - sendo ínfima a pequena quantidade de droga encontrada em poder do réu, o fato não tem repercussão na seara penal, à míngua de efetiva lesão do bem jurídico tutelado, enquadrando-se a hipótese no princípio da insignificância - habeas corpus concedido. (STJ, HC 17956-SP, rel. Min. Vicente Leal).

Também a Suprema Corte já reconheceu o princípio da insignificância nessa área. De qualquer modo, é certo que sua clássica posição em matéria de drogas é negativa: "Direito penal e processual penal. Posse ilegal de substância entorpecente (art. 12 da lei nº 6.368/76): pequena quantidade. Princípio da insignificância ou crime de bagatela. alegação de falta de justa causa para a ação penal (atipicidade material da conduta). "Habeas corpus". 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não abona a tese sustentada na impetração (princípio da insignificância ou crime de bagatela). Precedentes. 2. Não evidenciada a falta de justa causa para a ação penal, o "H.C." é indeferido (STF, HC 81641-RS, rel. Min. Sydney Sanches, DJ 04-04-2003, p.51).

Posto isto, julgo IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para ABSOLVER o réu da imputação que lhe é feita, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Oportunamente, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. Custas na forma da lei.

P.I.C.

Pirassununga, 07 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA